

0001752-66.2022.8.26.0024

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Quadrilha ou Bando

Magistrado: Pedro Luiz Fernandes Nery Rafael

Comarca: Andradina

Foro: Foro de Andradina

Vara: 3ª Vara

Data de Disponibilização: 05/12/2022

... com anotações por crimes patrimoniais, de tráfico de drogas ou relacionados a armas de fogo.

Veja-se a seguinte documentação, relativamente a cada acusado dos autos, todos com antecedentes criminais em período e natureza condizentes aos da associação criminosa:

i) WYSLLEN NERES DE SOUZA, fls. 552/553, 579/580, 864/866, 1309 (condenação definitiva por homicídio em período ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Andradina

Foro de Andradina

3ª Vara

Rua Paes Leme, 2052, Andradina-SP - cep 16901-110

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0001752-66.2022.8.26.0024 - lauda SENTENÇA

Processo Digital nº:

0001752-66.2022.8.26.0024

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Quadrilha ou Bando

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial - 113/2016 - 2º Distrito Policial de Andradina, 01/2017 - DIG - Delegacia de Investigações Gerais de Andradina

Autor:

Justiça Pública

Réu:

SAYMON RODRIGUES BRESSAN DA SILVA

Justiça Gratuita

O Ministério Público ofereceu denúncia contra SAYMON RODRIGUES BRESSAN DA SILVA (além de outros réus presentes no processo originário, anterior ao desmembramento de fls. 1327) imputando-lhe a prática do crime de participação em organização criminosa (Art. 2 "caput" § 2º § 4º, I do(a) LEI 12850/2013(Denúncia).

Narra a denúncia que em datas e horários diversos, entre os anos de 2016 e 2019, nesta cidade e comarca de Andradina: a) JUNIOR FELIX ALVES DE GODOY, qualificado às fls.39, 638/640, 712; b) SAYMON RODRIGUES BRESSAN DA SILVA, qualificado às fls.50 e 609, 711; c) THOMAZ VICTOR FERNANDES DE ALMEIDA, qualificado às fls.277/278, 437/438 e 612, 641/644, 713; d) MASAI WESLEY PERES DA SILVA, qualificado às fls.465/466 e 620, 715;e) MATHEUS REZE GOMES, qualificado às fls.457, 717 755; f) ALISSON RODRIGUES FRANCISCO, qualificado às fls.455/456, 485 e 623, 716; g) WESLEY JHONATAN SILVA DE OLIVEIRA, qualificado às fls.277/278, 714; e h) WYSLLEN NERES DE SOUZA, qualificado às fls.161, 541/545 e 618, 718 dos presentes autos, atuando em concurso e com unidade de desígnios entre si e juntamente com os inimputáveis Yuri José Paro de Oliveira (fls.16 e 44), Gabriel Felipe da Silva Gomes (fls.52 e 196) e Francisco Daniel Araújo (fls.64), se associaram, promovendo, financiando e

integrando, de forma estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, com objetivo de obter, direta e indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais.

A denúncia foi recebida em 05 de dezembro de 2019. O réu foi citado e apresentou resposta à acusação.

O feito foi desmembrado em relação ao acusado, por não ter sido intimado para a audiência de fl. 1327, aproveitadas as provas produzidas no processo originário, já que produzidas na presença de seu defensor, e sem objeção deste.

Após regular instrução, o Ministério Público manifestou-se pela condenação, com pedido de desclassificação para o crime do art. 288 do CP, entendendo demonstradas a materialidade e autoria do delito imputado; a d. Defesa, por sua vez, requereu preliminarmente nulidade por cerceamento do direito de defesa, por ausência de intimação do réu para a audiência de instrução e no mérito absolvição por insuficiência probatória.

É o relato do necessário. Fundamento e DECIDO.

Inexistem nulidades ou irregularidades a serem sanadas. O feito tramitou regularmente. Não foram arguidas preliminares ou questões prejudiciais aptas a impedir o prosseguimento da marcha processual, razão pela qual passo à análise do mérito da lide.

Quanto à arguição de nulidade por cercamento, anoto deva ser prontamente rechaçada. É que a Defesa técnica de SAYMON participou integralmente da colheita da prova em audiência de instrução e julgamento (fl. 1327) e foi expressamente instada a se manifestar sobre as provas produzidas à fl. 1354, ocasião na qual poderia requerer a repetição dos elementos já realizados, mas nada falou, indicando inclusive pela ciência de que as testemunhas já haviam sido ouvidas.

Em nova audiência, instada a se manifestar, na fase do CPP 402, a Defesa do acusado nada disse, deixando de apresentar qualquer objeção ao seguimento e julgamento do feito.

Convém destacar que a arguição, nesta fase, e após duas oportunidades para tanto, mostra-se totalmente extemporânea e em descompasso com o atual entendimento sobre as nulidades processuais e o momento oportuno de serem manifestadas.

A Defesa também não apontou concreto prejuízo ao réu, já que este limitou-se a negar sua participação nos fatos.

Veja-se o entendimento do STJ a respeito da questão: O reconhecimento de nulidades no curso do processo penal, seja absoluta ou relativa, reclama uma efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP (pas de nullité sans grief). O atendimento ao pleito defensivo resultaria em implícita aceitação da chamada "nulidade de algibeira" - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura. Ressalta-se, a propósito, que tal atitude não encontra ressonância no sistema jurídico vigente, pautado no princípio da boa-fé processual, que exige lealdade de todos os agentes processuais - AgRg no HC 710305 / PB - 5ª Turma - julgado em 14/06/2022.

Conforme já decidido pelo STJ em outra oportunidade "É inadmissível a chamada 'nulidade de algibeira' - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura" - AgRg no HC 732.642-SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDF), Quinta Turma, por unanimidade, julgado em 24/05/2022, DJe 30/05/2022.

Assim é que, ausente manifestação no momento oportuno, e sem demonstração de prejuízo ao réu, deixo de acolher o pedido de nulidade.

Após detida análise das provas produzidas e sopesadas as alegações das partes, conclui-se pela procedência da acusação.

Com efeito, a ocorrência do delito foi demonstrada pelos elementos da investigação (Inquérito de fls. 11/284, especialmente fls. 27/33, 81, 136/139, 178/179, 180/189, 190/193, 213/220, 227/230, além de fls. 328/329, 532/537 e de fls. 194/198, 567/568, 588, 825/828 e 1211/1212, pertinentes ao acusado SAYMON), bem como pelo resultado da instrução em juízo.

A autoria também foi comprovada, pelos elementos já indicados, prisão em flagrante e pelos consistentes relatos das testemunhas.

A prova oral, produzida sob o crivo do contraditório, foi no seguinte sentido (processo originário 5337-39.2016.8.26.0024) e neste:

Marcelo Oliveira Dias, policial civil e testemunha, narrou que a "guerra" de bairros existe, desde 2008 registrando aproximadamente 38 homicídios por ano, uma média de 3 ao mês. Tem como objetivo matar o bairro rival. Os líderes das gangues ostentam e fazem camisetas e tatuagem como forma de demonstrar que pertencem ao grupo.

A testemunha e policial civil, Jonas Eduardo Canato, disse que há anos existe a "guerra" de gangues responsável por diversos crimes, sendo o de homicídio mais grave. Na época dos fatos, os réus eram vinculados a essas guerras. Para a execução do crime há todo um planejamento e premeditação por parte dos autores.

A testemunha protegida relatou que já ouviu falar o nome dos réus, mas não convivia com eles no dia a dia. Sabe que em Andradina existem "guerras" entre bairros rivais. O nome dos réus já foi vinculado a essas guerras por comentários que ouviu. O Delegado de Polícia e testemunha, Marcelo da Silva Zompero, afirmou que a dita guerra começou por ciúmes - a partir daí, um bairro virou inimigo do outro e desencadeou guerras.

O Delegado de Polícia e testemunha, Raoni Manoel Spetic da Selva, contou que as "guerras" existem, e que os réus possuíam vínculos com as organizações responsáveis por elas; porém, atualmente, os réus Mateus Reze Gomes, Júnior Félix Alves de Godoy e Masai Wesley Peres da Silva, não integram mais.

Interrogado, o réu Júnior Félix Alves de Godoy afirmou que conhece os outros réus, exceto Thomas Victor Fernandes de Almeida, porém não sabe sobre a existência de "guerras" entre bairros, tampouco se os réus integram a organização. Em outubro de 2016 estava preso. Nega qualquer envolvimento com as guerras.

Thomaz Victor Fernandes de Almeida, também réu, relatou que não integra associação criminosa, e nem poderia estar envolvido nas guerras, pois se encontrava preso na maior parte do período de 2016 a 2019. Apenas conhece o réu Saymon Rodrigues Bressan da Silva, os demais não possui nenhuma relação.

O réu Masai Wesley Peres da Silva, falou que conhece todos os outros, ficou preso desde 2015 e saiu apenas em 19/01/2022, assim, não teria como participar de associação criminosa. Ao que tange a rivalidade de bairros, não garante sua existência, apenas demonstra o conhecimento de crimes por meio de comunicação de massa.

Wesley Jhonatan Silva de Oliveira, réu, alegou que a rivalidade de bairros existe, porém não tem envolvimento com nenhuma organização. Conheceu Thomas na penitenciária e os demais conhecia da Vila Mineira.

O réu Wylsen Neres de Souza disse que não há rivalidade entre os bairros, e que os ataques que acontecem são por motivos individuais. Em 2016 estava preso, motivo pelo qual não o permite integrar associação criminosa.

Em seu interrogatório, o réu SAYMON disse reconhecer a existência de uma "guerra de gangues" e rivalidade entre bairros, onde as pessoas atiravam umas nas outras, mas negou ter feito parte disso. Falou que dos réus, conhece apenas Thomaz, primo de sua atual namorada. Mora na Vila Mineira e já morou no bairro Pereira Jordão.

Como já colocado no processo originário, o contexto probatório não deixa dúvidas de que a imputação do delito de associação criminosa é procedente.

De início, deve-se dizer que o presente processo trata de acusação de crime praticado em concurso necessário de pessoas, de autoria coletiva, portanto, nos quais se abranda o requisito de descrição minuciosa da conduta de cada agente, quando esta não se mostrar possível.

Nas palavras da doutrina "tem-se admitido ofereça o promotor uma denúncia genérica, em relação aos coautores e partícipes, quando não se conseguir, por absoluta impossibilidade, identificar claramente a conduta de cada um no cometimento da infração penal".

Vai a jurisprudência no mesmo sentido (STF, 1ª Turma, julgado em 24/08/2020 - HC 186849 AgR): 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, em se tratando de crimes praticados por mais de um agente, não se pode

confundir a denúncia genérica com a denúncia geral, sendo certa a impossibilidade de, nesse momento processual, se exigir do órgão acusador o esgotamento das minúcias dos fatos incriminadores postos sob investigação (HC 178.837, Rel. Min. Luiz Fux). E mais: nos crimes societários é prescindível a descrição minuciosa e detalhada das condutas de cada autor, bastando a descrição do fato típico, das circunstâncias comuns, os motivos do crime e indícios suficientes da autoria ainda que sucintamente, a fim de garantir o direito à ampla defesa e contraditório (HC 136.822, Rel. Min. Luiz Fux).

E o caso dos autos comporta peculiaridade que merece destaque. Os agentes a quem se imputa a conduta de estarem associados praticavam diversos delitos por uma razão rudimentar e primitiva, a mera rivalidade entre bairros, e não por questões econômicas, de disputa de território, venda de drogas ou outras relacionadas à criminalidade organizada dos tempos atuais. Isto implica no fato de que o próprio planejamento e vínculo manifestam-se de formas distintas, em atos que, afinal, estavam ligados a um motivo subjacente a indicar um vínculo associativo entre os réus, mas praticados de forma esparsa e sem periodicidade definida, o que poderia gerar a falsa impressão de serem atos isolados. Tal elemento é justificador da impossibilidade absoluta de definição extremamente precisa da conduta de cada um no que diz respeito ao planejamento e execução dos crimes contra rivais, mas não impede a punibilidade dos agentes por terem se associado, por período relevante, para a prática de crimes em sequência nesta Comarca.

Fixado tal ponto, de cunho processual, no plano material é certo que a "existência" da guerra de gangues, além de ser um fato praticamente público e notório nesta Comarca, está suficientemente demonstrada pelos elementos de fls 27/33, 81, 136/139, 178/179, 180/189, 190/193, 213/220, 227/230, além de fls. 328/329, 532/537, além da prova oral produzida em audiência. Diz-se "fato público e notório" pois, apesar dos fatos dos autos dizerem respeito ao período de 2016 a 2019, ainda na atualidade são comuns as menções à famigerada "guerra de gangues" nas mais diversas ocasiões (em audiências de instrução ou Plenários do Júri, em palestras em eventos jurídicos, reuniões com órgãos de segurança ou mesmo em conversas do cotidiano entre os que atuam junto ao sistema de Justiça).

Aliás, tendo assumido minhas funções nesta Comarca em fevereiro de 2021, ou seja, 5 anos após o período retratado na denúncia, já atuei em alguns processos em que ocorreram crimes praticados em ataques reveladores da persistência da rivalidade entre membros da cidade de Andradina, sem maiores razões além do pertencimento a determinado bairro ou situação similar. A título de exemplo, cite-se o 1500382-15.2021.8.26.0605, processo de 2021 em que já houve condenação definitiva do agente em Plenário do Júri, no qual houve encontro fortuito entre o réu e a vítima em um posto de gasolina, que culminou em tentativa de disparos e agressão sem qualquer outra razão e o 1500104-14.2021.8.26.0605, em que um adolescente matou a vítima também em razão da denominada "guerra de gangues" (fato especificado na representação do Ministério Público), de abril de 2021 e que culminou em medida de internação.

Outro exemplo extremamente ilustrativo da persistência da violência aparentemente gratuita entre jovens nesta Comarca é justamente a morte de um dos réus deste feito, retratada no boletim de ocorrência de fls. 1325/1326.

Este é exatamente o caráter da associação revelada nos autos. Fatos que iniciaram por questões banais e escalaram para uma série de ataques entre pessoas de bairros rivais, pela simples e primitiva razão de sentimento de pertencimento a um local determinado e de exclusão daqueles que são da outra localidade.

E para propiciar tais ataques, os agentes envolvidos praticaram uma série de crimes "acessórios", seja para garantir fundos ou instrumentos para a finalidade última, de vulnerar os rivais. Justamente aí é que se encontra a maior prova de vinculação dos agentes destes autos aos crimes de ataques aos bairros rivais, todos eles com anotações por crimes patrimoniais, de tráfico de drogas ou relacionados a armas de fogo.

Veja-se a seguinte documentação, relativamente a cada acusado dos autos, todos com antecedentes criminais em período e natureza condizentes aos da associação criminosa:

- i) WYSLLEN NERES DE SOUZA, fls. 552/553, 579/580, 864/866, 1309 (condenação definitiva por homicídio em período contemporâneo ao retratado nos autos);
- ii) JÚNIOR FÉLIX ALVES DE GODOY, fls. 45, 65, 72/73, 127/130, 185/188, 552/553, 558/559, 579/580, 681/688, 820/823, 1194/1196 (condenações definitivas por roubo e tráfico no mesmo período da associação criminosa);
- iii) ALISSON RODRIGUES FRANCISCO, o qual inclusive ostenta uma tatuagem com a sigla VM, conforme por ele assumido à fl. 487/488, além de fls. 45, 319/320, 552/553, 558/559 (sendo primo de Gabriel Felipe, adolescente implicado em vários atos), 579/580 e fl. 1287/1288 (condenação definitiva por disparo de arma de fogo, após desclassificação de imputação inicial de tentativa de homicídio, em período compatível ao da associação);
- iv) THOMAS VICTOR FERNANDES DE ALMEIDA, fls. 319/320, 558/559, 579/580, 824/833 e fl. 1211 (reincidência por crime de porte ilegal de arma de fogo, além de outros delitos);
- v) WESLEY JHONATAN SILVA DE OLIVEIRA, fls. 319/320, 552/553, 558/559, 579/580, 834/844, 851/854, 1232/1234 condenações definitivas por crimes de corrupção de menores, receptação e tráfico de drogas, praticados antes ou durante a associação aqui reconhecida;
- vi) MASAI WESLEY PERES DA SILVA, fl. 45, fl. 319/320, 558/559, 579/580, 845/850 e 1276/1277 (condenações definitivas por receptação e roubo, no mesmo período da associação aqui retratada);
- vii) SAYMON RODRIGUES BRESSAN DA SILVA, fls. 194/198, 567/568, 588, 825/828 e 1211/1212 (condenação definitiva por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo, sem recurso do acusado, no processo 0004496-44.2016.8.26.0024, que trata de fatos de 25/06/2016).

Cabe também destacar a comum utilização de adolescentes para a prática de atos de execução "em si" dos ataques entre os grupos rivais. Sabedores das consequências menos gravosas a tais pessoas, a prática tornou-se comum.

Importante também mencionar que os dois policiais civis (investigadores) e os dois delegados de polícia ouvidos foram deveras enfáticos ao atestar, sem nenhuma dúvida, para a existência da "guerra" entre os bairros rivais e a implicar todos os denunciados nos fatos correlatos.

E o testemunho dos policiais não deve ser desacreditado apenas pela sua condição funcional. Não demonstraram ser tendenciosos ou qualquer especial disposição para prejudicar os réus, devendo o seu testemunho ser valorado como qualquer outro. Esta é a jurisprudência já pacífica sobre a condição de testemunha dos policiais e outros agentes de segurança.

De seu lado, as versões dos réus mostraram-se contraditórias entre si e deveras evasivas. Todos com longo histórico criminal, narraram desconhecer a existência de ataques entre bairros (ou ao menos pessoas) rivais na Comarca, o que é um verdadeiro contrassenso, frente à existência de tantos ataques (como o ocorrido com o próprio Matheus Reze) e outros elementos (como as postagens de fls. 27/33) a não deixar dúvidas de que havia uma vinculação dos réus ao bairro Vila Mineira e consequente repercussão a pessoas oriundas de outros bairros. O fato de boa parte dos réus estarem em reclusão em parte do período estabelecido na denúncia não é fator que exclui a imputação, senão a confirma, já que a restrição de liberdade decorreu justamente de crimes graves praticados no contexto já mencionado (roubos, homicídios, tráfico de drogas etc).

Percebe-se, nesse sentido, que foram incapazes de infirmar o restante do contexto probatório, que lhes é francamente contrário, não apontando motivos aptos a motivar a desconsideração prova oral colhida ao longo da instrução e os demais elementos de investigação.

O certo é que houve demonstração de uma série de crimes e outros atos praticados no contexto de uma rivalidade entre bairros e que causou (e ainda causa) efetivos nocivos à Comarca como um todo, seja pela violência contra pessoas e o risco inerente de efeitos colaterais a inocentes, seja pelo fomento a prática de outros crimes para que os agentes consigam recursos para a referida violência.

E, na forma do CPP 383, deve-se acolher mesmo as razões trazidas pelo Ministério Público e já colocadas pela prova oral, em especial dos dois delegados de polícia

ouvidos.

Os agentes não se estruturavam como organização criminosa, mas estavam vinculados e associados para a prática de crimes com a finalidade última de rivalizar contra pessoas de localidades distintas da cidade. Assim é que a capitulação mais adequada ao caso é o crime de associação criminosa, previsto no art. 288 do CP.

Impondo-se a condenação, resta a fixação da sanção correspondente.

Critérios para fixação da pena:

Antes de iniciar a fixação da pena propriamente dita, cabem alguns esclarecimentos sobre os critérios gerais a serem utilizados para a dosimetria, especialmente sobre a forma de cálculo das frações de aumento e diminuição. A base de cálculo será o intervalo entre a pena mínima e máxima do delito, e não a pena mínima.

Na primeira fase, na qual fixa-se a pena-base, existem oito circunstâncias judiciais passíveis de valoração. A pena sempre partirá do mínimo previsto e, a cada circunstância judicial desfavorável ao acusado, somar-se-á à reprimenda mínima cominada a fração de um oitavo (pois são oito circunstâncias), calculada pelo intervalo entre o máximo e o mínimo de pena previstos em lei para o crime em questão. A partir deste intervalo entre a pena máxima e a mínima encontra-se a fração respectiva de um oitavo para cada circunstância desfavorável.

Exemplificando-se, para melhor compreensão: se um crime tem pena mínima de 12 anos e máxima de 20 (como ocorre com o tipo previsto no art. 159, § 1º do Código Penal), o cálculo das frações é feito sobre o intervalo de 8 anos entre a pena mínima e máxima, e não sobre os 12 anos da pena mínima. A cada circunstância negativa considerada somar-se-á à pena mínima 1/8 sobre oito anos, o que representa um ano.

Se não houver circunstância negativa, a pena-base será a mínima, de 12 anos; ao contrário, se todas forem desfavoráveis, a pena parte do máximo legal, 20 anos.

Tal forma possibilita ao mesmo tempo: i) controle sobre os patamares utilizados pelo julgador, que se move em espaço conferido pelo legislador por meio de critério racional; ii) proporcionalidade, pois cada circunstância terá, em regra, peso semelhante e será calculada de acordo com os patamares mínimo e máximo da pena, abarcando de forma global a gravidade do crime; iii) fixação da pena partindo sempre do mínimo legal, com a possibilidade de se chegar ao máximo previsto, caso as oito circunstâncias judiciais sejam desfavoráveis.

O critério também evita indesejáveis discrepâncias, como nos casos de crimes com pena mínima muito elevada ou diminuída. Se o cálculo partir da pena mínima, pode-se chegar a exasperações exageradas (como no caso da extorsão mediante sequestro seguida de morte, cuja pena mínima é de 24 anos) ou ínfimas (neste caso nunca se chegando perto da pena máxima cominada para o delito, como no crime de ameaça).

Ademais, permite que crimes que possuem a mesma pena mínima, mas diferentes penas máximas, justamente por serem de gravidade distinta (como a lesão corporal do caput e a figura do § 9º), sejam apenados adequadamente, cada um com sua gravidade e grau de censura já estipulados em lei. Seria injusto que para crimes de diferente gravidade a exasperação da pena-base partisse do mesmo patamar.

Via de regra, este será o critério utilizado na primeira fase. Diante da peculiaridade de cada caso as frações de cálculo poderão ser diminuídas ou aumentadas, para que se possa individualizar adequadamente a pena, de forma fundamentada (como por exemplo, nos casos de várias condenações criminais ou reincidência específica). O critério explicitado servirá sempre de parâmetro, porém não impedirá seja a pena-base fixada de modo diverso (para mais ou menos) se o caso assim recomendar (valendo isto também para a segunda fase).

Na segunda fase, na qual incidem agravantes e atenuantes, a fração usada para valoração será, no mais das vezes, de um sexto (1/6), calculado ou sobre o intervalo entre pena mínima e máxima, como acima, ou sobre a pena-base já fixada - o que for maior.

E utilizar-se-á o maior valor por uma razão simples: há uma hierarquia no sistema trifásico que deve ser respeitada. O sistema trifásico é escalonado, tendo cada fase maior relevância sobre a precedente. As circunstâncias do art. 59, valoradas pelo julgador, jamais podem preponderar sobre agravantes ou atenuantes, elevando a pena em patamar acima destas, que já foram estipuladas como mais graves de antemão pelo próprio legislador. A fração de 1/6 será utilizada pois é a menor prevista

para as causas de diminuição e de aumento de pena e, com isso, respeita-se novamente a hierarquia do sistema trifásico.

Por fim, como não poderia deixar de ser, as causas de aumento ou de diminuição de pena incidirão sobre a reprimenda fixada provisoriamente na primeira e segunda fases, de forma sucessiva (incidindo umas sobre as outras, em cascata), segundo entendimento preponderante nos tribunais. Do contrário poderia se chegar ou a penas negativas, no caso de diversas causas de diminuição, ou na utilização de critérios distintos para causas de aumento e de diminuição, o que não é isonômico.

Friso que o critério ora explicitado vem sendo consagrado pelo C. Superior Tribunal de Justiça (HC 498586 / SP - 5ª Turma - julgado em 11/02/2020), verbis:

"2. A individualização da pena é uma atividade vinculada a parâmetros abstratamente cominados pela lei, sendo permitido ao julgador, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, ressalvadas as hipóteses de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, é inadmissível às Cortes Superiores a revisão dos critérios adotados na dosimetria da pena. 3. As agravantes não necessariamente incidem sobre o resultado da pena-base, cujo acréscimo de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância negativa multiplica o intervalo de pena decorrente da diferença entre a pena mínima e máxima cominadas ao tipo, para então somar à pena mínima. Portanto, as agravantes incidirão sobre a pena-base se for maior ou igual ao intervalo de pena em abstrato do preceito secundário, caso contrário, malgrado haver pena concreta dosada, as agravantes serão fixadas com parâmetro na base de cálculo das circunstâncias judiciais, sob pena de as agravantes serem menos gravosas do que meras circunstâncias judiciais". E ainda (AgRg no REsp 1704633 / TO - 6ª Turma - julgado em 24/09/2019): "A divisão do intervalo entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato pelas oito circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP é um, entre outros, dos critérios que podem ser utilizados na fixação da pena-base".

Dito isso, passo efetivamente a fixar a pena.

Na primeira fase, observo que o réu foi definitivamente condenado por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo (fl. 1211, sem recurso da defesa, diga-se) cometidos em 06/07/2016, ou seja, em período compreendido à existência da associação ora reconhecida (que vai de 2016 a 2019). A pena-base assim deve ser exasperada em 1/8, por configurar o fato antecedente criminal, já que cometido crime anterior ao fim dos fatos deste processo (2016 a 2019), cujo trânsito se deu durante o trâmite deste feito. Veja-se, o entendimento do STJ sobre a matéria (HC 171212/DF - 6ª Turma - DJe 20/08/2015): "O conceito de Maus antecedentes, por ser mais amplo, abrange não apenas as condenações definitivas por fatos anteriores cujo trânsito em julgado ocorreu antes da prática do delito em apuração, mas também aquelas transitadas em julgado no curso da respectiva ação penal, além das condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos, as quais também não induzem reincidência, mas servem como Maus antecedentes."

Ademais, pela ampla repercussão e graves efeitos gerados na Comarca de Andradina, entendo que os fatos desbordaram da gravidade inerente ao tipo penal. Como dito, ainda hoje, diversos crimes e atos infracionais são praticados no tal contexto da rivalidade entre bairros, o que instalou uma cultura de criminalidade e violência em Andradina, a demandar resposta estatal condizente e, portanto, mais rigorosa, na forma do CP 59.

Em razão de tais consequências e maior reprovabilidade da conduta, cabe nova exasperação em 1/8, totalizando-se portanto 1/4.

Ressalto que a pena parte do mínimo legal (1 ano) e a este patamar serão somados os montantes das frações encontradas a partir do intervalo entre a pena mínima e máxima, e não a partir da pena mínima.

NÃO SE TRATA DE UTILIZAÇÃO DO CRITÉRIO DO TERMO MÉDIO (O QUAL FARIA A PENA-BASE PARTIR DE 2 ANOS E NÃO DO MÍNIMO), TAMPOUCO DE ERRO ARITMÉTICO.

Trata-se de utilização de distinta base de cálculo para encontro das frações de mudança da pena, utilizando-se o resultado do intervalo entre a pena mínima e máxima, e não a pena mínima, critério este que considera a gravidade do crime de forma global conforme estipulada pelo legislador e mostra-se mais proporcional ao

juízo prévio feito pelo parlamento sobre a natureza do crime (caso contrário, crimes com pena mínima igual e pena máxima diversas, como o estupro e o homicídio, o furto qualificado e a corrupção passiva, etc, teriam idêntico apenamento, o que não se mostra de fato adequado, pois o legislador já estabeleceu distinção prévia de gravidade, a ser observada pelo julgador; já crimes com penas mínimas muito elevadas, teriam exasperações exageradas, como a extorsão mediante sequestro com resultado morte, com pena mínima de 24 anos).

De toda forma, destaco novamente que o tópico acima ("critérios para fixação da pena") estabelece as justificativas pelas quais a individualização da pena resta melhor assegurada por esta forma de cálculo, que é diferente do padrão normalmente adotado (mais cômodo para cálculos, mas que desconsidera inúmeros fatores de proporção e postulados a respeito da prevalência dos critérios de lei sobre critérios subjetivos), mas que é referendado por argumentos racionais e também pela jurisprudência do STJ (HC 498586/SP - 5ª Turma - julgado em 11/02/2020 e AgRg no REsp 1704633/TO - 6ª Turma - julgado em 24/09/2019).

Feito novamente tal esclarecimento, adiciono à pena mínima (1 ano) o montante de 6 meses de reclusão, equivalente a 1/8 de 2 anos, ou de 24 meses, (intervalo de pena previamente estabelecido pelo legislador ao considerar globalmente a gravidade do crime) e estabeleço a pena-base em 1 ano e 6 meses de reclusão.

Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes.

Na terceira fase, presente a causa de aumento prevista no parágrafo único do art. 288, pois além do uso de arma de fogo, havia a comprovada participação de adolescentes nos atos mencionados nos autos. Havendo as duas circunstâncias mencionadas em lei, e pela quantidade de atos praticados ao longo dos anos, entendo como proporcional e adequado o aumento de metade, pela maior vulneração aos bens jurídicos tutelados pela norma incriminadora. Assim, a pena vai a 2 anos e 3 meses de reclusão, a qual torna definitiva.

O regime inicial, tendo em vista a quantidade de pena, circunstância judicial negativa, antecedente criminal reconhecido e gravidade em concreto do fato, deve ser o fechado.

Inviável a substituição da pena, pela gravidade do fato (que envolve inclusive violência) e por não ser suficiente para prevenção e reprovação do delito (CP 44, I, II e III).

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a acusação e, na forma do CPP 383, CONDENO SAYMON RODRIGUES BRESSAN DA SILVA, pela prática do crime de associação criminosa, previsto no art. 288 do Código Penal, à pena de 2 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Recurso em liberdade. Condeno o réu ao pagamento das custas do processo em 100 UFESPs, com as ressalvas da gratuidade, que fica aqui deferida.

Com o trânsito em julgado: i) comunique-se ao IIRGD e ii) Justiça Eleitoral, iii) anote-se a condenação (art. 372 das NSCGJ) e iv) expeça-se guia de recolhimento. Determino apensamento deste feito ao processo 0005337-39.2016.8.26.0024, para processamento e julgamento conjunto de eventual apelação, evitando-se decisões conflitantes.

Publique-se. Intime-se na forma legal.

Andradina, 05 de dezembro de 2022.

Pedro Luiz Fernandes Nery Rafael
Juiz de Direito
(assinatura eletrônica)

Providências: apensar ao 0005337-39.2016.8.26.0024 para processamento conjunto.